

1500341-35.2019.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... penitenciários, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500341-35.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-35.2019.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAELA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LARISSA BONI VALIERIS

Vistos.

A ré RAFAELA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do Art. 33, caput, c.c. Art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de fevereiro de 2019, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro de cocaína, com peso líquido de 102,75 gramas, acondicionada em embalagem plástica transparente, folha de carbono e grafite em pó com a finalidade de inibir eventual visualização por escaneamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação preliminar de fls. 28/33. Segundo a denúncia, na data dos fatos, a denunciada dirigiu-se ao mencionado estabelecimento prisional, local em que seu companheiro Maxsuel Fernando Palma dos Santos se encontra encarcerado (fls. 18/20). Ocorre que, durante revista no scanner corporal, foi constatado que havia algo de anormal em seu corpo e, após revista pessoal e em sala reservada, a autora retirou 01 (um) invólucro em formato oval acondicionado com fita adesiva de cor preta, plástico transparente, folha de carbono e grafite em pó, o qual em seu interior continha cocaína.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01).

Auto de exibição e apreensão (fl. 12).

Laudo pericial (fls. 28/33, 92/95 e 84/86).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 37/41).

Recebida a denúncia em 14 de novembro de 2019 (fls. 148-149).

A ré apresentou defesa preliminar (fls. 111/132).

Realizada audiência de proposta de acordo de não persecução penal que restou prejudicada ante a ausência da ré e de seu advogado, decretando-se assim, sua revelia. Audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 24/01/2022 (fls. 202/203).

Designada audiência foi ouvida a testemunha Elisângela Cristina.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º da Lei de Drogas e a aplicação da causa de aumento do art. 40, III da referida lei, sendo fixado regime semiaberto para cumprimento de pena.

Por outro lado, a defesa argumentou pela absolvição, uma vez que se trata de conduta atípica, sendo comprovada a ineficácia absoluta do meio, pois a autora seria submetida a minuciosa inspeção, razão pela qual se trataria de crime impossível.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a presente ação.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo pericial de constatação (fls. 31-33), documentos de fls. 15-23, exame químico toxicológico (fls. 93-95), bem como pela prova oral coligida.

A autoria é inconteste.

O laudo de exame químico constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime. A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade da ré acerca dos fatos a ela imputados na exordial acusatória.

A agente penitenciária Elisângela Cristina Vicente Gonçalves de Queiroz, em seu depoimento, narrou que é agente penitenciária e na data dos fatos a visitante RAFAELA DOS SANTOS, a qual consta no rol de visitas como companheira de detento, passava por scanner corporal, sendo verificado que havia algo de anormal em seu corpo; que após revista pessoal e em sala reservada, a autora retirou de sua genitália, 01 (um) invólucro em formato oval acondicionado com fita adesiva de cor preta, plástico transparente, folha de carbono e grafite em pó (com finalidade de inibir eventual visualização com o aparelho de escaneamento), o qual em seu interior continha substância amarelada aparentando ser cocaína.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos agentes penitenciários, a condenação por tráfico não pode ser afastada. O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer consigo ou manter em depósito a droga já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO - In DJU 04.06.1993 - p. 11.012).

No mesmo sentido:

"Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 - Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ - IN RJTJESP 97/512).

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Outrossim, não se pode falar em ineficácia absoluta do meio, uma vez que o fato de

ser submetida a inspeção não inviabiliza a consumação, sendo certo que a ré empreendeu esforços para a consumação, tendo em vista ter sido encontrado em sua genitália um invólucro em formato oval contendo cocaína, que estava acondicionado com fita adesiva de cor preta, plástico transparente, folha de carbono e grafite em pó com a finalidade de inibir eventual visualização por escaneamento. Destaca-se que o mesmo raciocínio restou evidenciado em entendimento sumulado, embora para crime diverso: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". (SÚMULA 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Ante o exposto, conclui-se pela total procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

Assevero que, inexistem nos autos outros elementos de prova que indiquem que o denunciado se dedique a atividades criminosas.

Deste modo, de rigor a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, que deverá ser utilizada no seu grau máximo, em razão da quantidade de droga apreendida em poder do denunciado.

Isto posto, dou o réu como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Passo à dosimetria das penas, nos termos do artigo 68, do Código Penal. Atento às disposições do art. 59, do Código Penal, bem como nos termos do art. 42, da Lei n.º 11.343/06, passo a fixar a pena-base

Passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, como as normais ao tipo e fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Por outro lado, na terceira fase, considerando que as drogas eram transportadas de um Estado da Federação para outro, nos termos do inciso III, do artigo 40, da Lei n.º 11.343/06, aumento de 1/6 a pena, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão. A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei no. 11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o ré é primária e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa, resultando a pena em 01 ano 11 meses e 10 dias de reclusão.

O regime inicial será o semiaberto, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que o tráfico foi praticado em estabelecimento prisional, possibilitando a entrada da droga no local e acesso dos detentos à substância extremamente danosa, tratando-se de cocaína.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no. 11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal 500 dias-multa, o que perfaz 583 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 194 dias-multa. Sendo o acusada pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração. Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 194 dias-multa. Diante do que dispõe o artigo 44, do Código Penal, é possível verificar que a acusada faz jus à substituição.

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER PONDERADA ISOLADAMENTE. 1. Os mais recentes julgados desta Corte têm-se orientado no sentido de que o fato de o tráfico de drogas ter sido praticado no intuito de introduzir substâncias ilícitas em estabelecimento prisional, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo essa circunstância ser ponderada com os demais requisitos necessários para a concessão da benesse. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. Sendo a agravada primária e de bons antecedentes, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal e, ainda, diante da quantidade e natureza da droga apreendida (62,60 g de maconha), é razoável e proporcional o deferimento da substituição da pena. 3. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no REsp

1359941/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e o faço para condenar RAFAELA DOS SANTOS, qualificada nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. parágrafo 4º do mesmo artigo, e artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando-se as suas condições financeiras desfavoráveis, com os reajustes legais.

Presentes os requisitos legais e com fulcro no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, que consistem em prestação de serviço à comunidade, pelo prazo da pena fixada, em instituição a ser designada pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Faculto a ré o direito a recorrer em liberdade.

Deixo de aplicar a detração, diante do curto lapso de prisão provisória por este processo.

Deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Guarulhos, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA